



生态文明保障的刑法机制*

焦 艳 鹏

摘 要：当前，我国正处于生态文明建设与全面推进依法治国的关键时期，运用法治方式加强生态环境保护是应有之义。环境犯罪需要刑法惩治，生态文明保障需要刑法机制。在生态文明建设中，需科学配置刑法在法益保护、人权保障与秩序维护三者之间的机能，以应对风险社会的现实风险，并保持刑法的基本品性。生态法益作为人在生态文明时代权利形态的一种，应受到刑法的有效保障。生态法益的有效保障，在刑事立法中要求法益的类型化、具体化和可测量化，在刑事司法中要求有效的法益识别、法益度量和精细化司法。生态文明的刑法保障受到整体法治价值的牵引与制约，刑法需与宪法、行政法、环境法等共同承载保护生态法益的使命。刑法技术与生态科学的有机结合，将有助于生态社会中刑法对人的价值的保障。

关键词：生态文明 环境保护 刑法机制 环境犯罪 生态法益

作者焦艳鹏，重庆大学法学院教授（重庆 400044）。

党的十八大以来，我国进入生态文明建设的新时期。加强生态环境保护，为人民群众提供良好的生态环境，已成为政府的重要职责。在生态文明建设中，运用刑法手段惩治污染环境、破坏生态的犯罪行为，在我国司法中已有大量案例和丰富的实践经验，亟需理论概括和提炼，进而为制度的构建与运行提供依据。

惩治环境犯罪、预防环境风险，是刑法在生态文明时代的重要使命。在传统风险依然存在，新型风险不断增加的情势下，伴随着复杂的经济社会发展，刑法在承担保护国家与人民、打击犯罪的传统功能之外，对变动社会中新兴价值的保护功能也在增强。在人身法益、财产法益等传统法益之外，生态法益作为人在生态社会的新型权利形态，其内容不断得到填充，迫切需要得到刑法的有效保障。

基于生态文明建设与法治保障之间的密切关联，在生态文明建设的过程中，中国特色社会主义法治理念应得到充分体现：既要打击环境犯罪、保护人民环境权益，

* 本文为中央高校基本科研业务经费面上项目“基于多元效能的环境行政执法与刑事司法衔接机制研究”的研究成果之一。



也要坚持刑法总体谦抑,实行宽严相济的刑事政策;既要通过刑罚配置发挥刑法的惩罚功能,也要创新机制,通过多元治理完善环境犯罪的预防机制;既要加强生态文明保障的刑事立法机制,增强立法科学性,也要提升生态文明的刑事司法水平,精细化司法,让人民群众在每一个生态环境刑事案件中感受公平正义。

一、生态文明保障刑法机制的基本范畴

生态文明保障的刑法机制,是指在生态文明建设中,作为部门法的刑法,通过一定的作用机理,发挥其预设功能,保障相关主体的权利或利益,进而促进生态文明建设目标实现的法律机制。对生态文明建设进行刑法保障,需明确生态文明的基本形态与刑法的作用机理,并实现两者的有机结合。

生态文明是一个高度浓缩且具有多种语义的概念,其基本形态存在多重维度。有学者将生态文明理解为一种理念,如认为:“经过改革开放,中国虽然基本建立了社会主义市场经济体制,但这个体制没有体现生态文明理念和原则,因此,建立符合生态文明理念和原则的新制度,其核心是必须正确认识 and 处理好环境保护与经济发展的关系。”^①有学者认为,生态文明“既可以是人类在处理人与自然关系中所取得的积极成果的总和,也可以是一种更高级的社会形态”。^②还有学者认为,“文明作为人类文化发展的成果,是人类改造世界的物质和精神成果的总和,是人类社会的整体进步状态,包括文明的理念、文明的制度、文明的运行三个部分。”^③依此论理,生态文明可分为理念、制度、行为三种形态。作为理念形态的生态文明,主要是指从世界观层面上定位的人与自然的相互关系,正是在这个层面上,党的十八大报告中确立了“必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念”的提法,党的十九大报告进一步指出,“人与自然是生命共同体”;制度形态的生态文明,是指为了实现人与自然的和谐相处,国家在经济发展与环境保护等方面所建立的制度规范的总和;行为形态的生态文明,是指从微观层面而言,作为社会成员的各级各类组织或公民基于践行生态文明理念,遵守生态文明制度而依法从事的各类行为。^④

在刑法学视野下,生态文明的保障需要刑法机制的介入。刑法机制虽非我国目前刑法学研究的核心范式,但其概念意蕴与刑法学价值颇受关注。20 世纪 90 年代,有刑法学者对其作出界定,认为“刑法机制是指刑法运行的结构与机理。一般来说,机制是指事物的构造、功能及其相互关系。刑法作为一种社会事物,其存在与发展

① 吕忠梅:《论生态文明建设的综合决策法律机制》,《中国法学》2014 年第 3 期。

② 王灿发:《论生态文明建设法律保障体系的构建》,《中国法学》2014 年第 3 期。

③ 吕忠梅:《中国生态法治建设的路线图》,《中国社会科学》2013 年第 5 期。

④ 如各类企业履行环境保护义务而缴纳排污费用,公民个人旅行的生活垃圾减量化、对生活垃圾进行分类投放等的个人环境保护义务都可以理解为这里的行为层面的生态文明。



也有着内在机制。在这个意义上,我们可以将刑法机制视为刑事法律活动的各个阶段及其功能的互相配合协调的有机统一”。^①在对刑法机制作出界定后,学者从刑事立法与刑事司法、定罪与量刑、判刑与行刑三对范畴的协调上对刑法机制展开论述。进入21世纪,在刑事一体化^②思想指导下,刑法机制的概念及学说得到进一步发展。有学者认为,刑法机制是指“刑事立法与司法适用之间的相互关系和作用过程,二者分别遵循自身的运作规律并相互促进,使刑法立法和司法适用有机配合,保证刑法保护社会和保障人权的功能得到最大程度的发挥”;^③有学者指出,“刑法机制这一概念的涵义是刑法运作的方式和过程,亦即刑法的结构产生功能的方式和过程”;^④有学者在承认上述刑法机制内涵界定具有合理性的基础上,认为“刑法机制所能揭示的是刑法系统内部的结构及其内在运作机理,而不是刑法系统与其外部世界的关系”。^⑤

笔者认为,刑法机制是居于刑法目的、刑法机能或刑法功能维度之下的刑法学范畴。刑法机制传达刑法功能,刑法功能服务于刑法目的。无论刑法的目的是“打击犯罪、保护人民”,还是“对法益的保护”,刑法对国家政权、社会秩序、公民权益的保障都是其基本功能,都应成为刑法机制所传送的核心价值。对刑法机制的定位与分析将使刑法学从目的正当性的价值论证移转到功能有效性的科学论证上,既增进了刑法学研究的科学意味,又使刑法作为部门法,其作用机理的构建与解析可以从法理学中法律机制^⑥的范畴得到滋养。

吸收前人对刑法机制范畴的研究成果,并将其介于法治系统视野之下,笔者认为,刑法机制是指刑法功能据以发挥或实现的内部作用机理,其机理包括如下要点:第一,通过刑事立法确定犯罪行为的边界与类型。这个过程在本质上是对行为进行类型化并进行犯罪化,在此过程中,掌握刑事立法权的国家需对相关行为是否规定为犯罪进行考量。第二,通过刑事司法确认犯罪人并对其定罪量刑。该过程又区分

① 高明暄、陈兴良:《挑战与机遇:面对市场经济的刑法学研究》,《中国法学》1993年第6期。

② 刑事一体化思想是由德国学者首倡的刑法学思想,肇始于李斯特在100多年前提出的整体刑法学,即基本意蕴是将犯罪、刑事政策、刑法三个范畴作一体化考量。刑事一体化思想在我国的主要倡导者为储槐植教授。

③ 宗建文:《刑法机制研究》,北京:中国方正出版社,2000年,第4页。

④ 储槐植:《再说刑事一体化》,《法学》2004年第3期;储槐植等:《刑法机制》,北京:法律出版社,2004年。

⑤ 周少华:《刑法机能的发生机制——一个技术性描述》,《法商研究》2005年第2期。

⑥ 参见张文显:《构建社会主义和谐社会的法律机制》,《中国法学》2006年第1期;杨思斌、吕世伦:《和谐社会实现公平原则的法律机制》,《法学家》2007年第3期;汪习根:《化解社会矛盾的法律机制创新》,《法学评论》2011年第2期;唐清利:《公权与私权共治的法律机制》,《中国社会科学》2016年第11期;等等。



为通过侦查程序确认犯罪人与通过刑事诉讼程序确认犯罪人是否构成犯罪及罪行大小两个阶段。第三,通过刑事责任的承担惩罚犯罪人并发挥一般预防功能。此过程本质上是通过刑事责任的承担使犯罪人得到惩罚,减少其再犯罪可能,其得到惩罚的外观也使公众受到教育与震慑,最终达到特殊预防与一般预防的统一。^①

依上文对生态文明基本形态与刑法机制内涵的解析,生态文明保障的刑法机制应主要包括刑事立法机制、刑事司法机制等要素。本文以我国生态环境刑法治理的实践为切入点,以生态文明保障的刑事立法机制、生态文明保障的刑事司法机制的构建为主要内容进行论述。^②

二、生态文明保障刑法机制的理论依托

近年来,针对生态文明的刑法保障与我国的环境犯罪的治理模式,学界探讨颇多,其核心命题在于:刑法对于生态环境领域应否介入以及如何介入,其依据何在?围绕上述命题,我国学者在刑法理论上特别是在解释论意义上展开了分析,主要体现在生态文明保障刑法机制与法益理论、风险刑法理论、社会危害性理论三个层面。

(一) 生态文明保障的刑法机制与法益理论

生态文明保障的刑法机制与法益理论,可以进一步归纳为基于法益理论的生态文明刑法保障探究。上述命题的实质是在生态文明建设背景下,生态环境领域相关犯罪的实质客体的解释问题。大陆法系法益理论认为,犯罪是侵害或威胁法益的行为,在具体的犯罪类型或具体化的犯罪事实中,所侵害与威胁的法益可以具体化,即这些法益可具体化为财产法益、生命法益、国家法益等。^③

毋庸置疑,污染环境或破坏生态行为,^④是具有侵害传统刑法法益向度的。在具体情境中,污染环境行为可造成财产损失^⑤或人身伤害,而财产利益与人身利益皆为传统刑法所保护的客体,也是传统犯罪所侵害的客体。依现行刑事立法,破坏生态行为经刑法调整后往往转化为破坏自然资源的行为,而自然资源的财产价值作

① 参见焦艳鹏:《法益理论的价值考量与适用维度的扩张》,《澳门研究》2013年第1期。

② 刑事司法之后还存在刑罚执行,但由于对刑罚执行特别是生态环境领域刑罚执行与刑法一般预防功能的评估理论及技术尚不成熟,本文对此不作专门探讨。

③ 参见张明楷:《法益初论》,北京:中国政法大学出版社,2003年。

④ 环境法学界一般将破坏环境资源的行为区分为污染环境类与破坏生态类,污染环境是指向大气、水体、土壤等排放有毒、有害物质导致环境受到污染的行为,破坏生态一般是指对具有生态价值的草原、森林、湿地等生态系统进行人为破坏,导致生态功能受损的行为。两者的主要区别之处在于是否有有毒有害物质介入。

⑤ 此种财产是指传统民法上的财产,如水污染中国家、集体或公民的水产品,大气污染中国家或公民的动产或不动产的价值损失。



为刑法保护的客体在立法技术上是可实现的。但对污染环境与破坏生态行为所侵害的客体究竟是传统法益还是新型法益,则可能具有不同解释。

污染环境或破坏生态行为,虽没有造成传统的人身法益或财产法益侵害,但已然造成环境管理制度破坏时,如何评价行为的危害性及所侵害的客体?有论者认为,此种情形下,若规定上述之行为为犯罪,则是因为刑法对秩序的保护,即刑法所保护的客体是国家秩序。^①但不容忽视的是,秩序并非可具体化与类型化的刑法法益,行政法所建立的管理秩序并不必然需要刑法同步保护,只有严重破坏行政法建立的管理秩序的行为方可认为是犯罪,即便认为侵害秩序的行为是犯罪,但仍应对行为所侵害的具体客体进行实质解释,而非仅以秩序为直接解释对象。^②

换言之,对污染环境与破坏生态行为所侵害的实质客体,需进行超越传统法益理论的重新界说。有学者提出了生态法益的概念,^③并进行了系统论证。笔者认为,生态法益并非是生态环境作为主体的法益类型,生态环境作为非人类存在物,不可能也没有必要成为法益主体。人作为法益主体的观念应得到坚持。生态法益是依据宪法或一般人权法准则确立的人在生态环境领域所享有的包括呼吸清洁空气、饮用清洁水源,在安宁、洁净的环境中生活,并可合理享有与利用自然环境或自然资源的权利或利益。^④生态法益可区分为可类型化形态与不可类型化形态两类。可类型化形态包括传统的人身法益与财产法益,不可类型化形态包括除上述人身法益与财产法益之外的其他生态法益。不可类型化的生态法益也应成为刑法保护的客体。破坏环境资源管理制度,虽没有造成可类型化生态法益侵害,但可能侵害不可类型化的生态法益,在符合实定法的犯罪构成要素的情形下,亦可构成犯罪。

将生态法益作为生态环境领域犯罪的实质客体,可以有效解决污染环境与破坏生态行为的刑法评价问题。既可以将传统法益作为环境犯罪的客体,也可以实现基于保障行政法律秩序价值实现的刑法功能配置,是通过刑法手段保护生态环境,并对相关行为作犯罪化处理的有力解释工具。

(二) 生态文明保障的刑法机制与风险刑法理论

风险刑法理论是近年来在我国产生较大影响,但也饱受批评的刑法思潮。大部

-
- ① 我国刑事立法即采此种观点,关于环境资源的犯罪规定在《刑法》第六章“妨碍社会管理秩序罪”之下。
- ② 如对刑法中保险诈骗罪所侵害法益的解释。若仅依据该罪名规定在《刑法》第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”之下,而解释为对经济管理秩序法益的侵害,而忽视该罪所规制行为对当事人即保险公司财产法益的侵害,显然是不妥当的。
- ③ 参见焦艳鹏:《刑法生态法益论》,北京:中国政法大学出版社,2012年。
- ④ 这种权利或利益已得到国际法律或宣言的认可。如1972年人类环境会议发布的《斯德哥尔摩宣言》、1992年巴西里约热内卢联合国环境与发展大会发布的《里约宣言》等。



分学者把风险刑法理论视为反思传统刑法理论的重要工具,主张按照风险刑法理论的一些基本原理对我国刑法进行改造,如主张犯罪前置化、法益抽象化、主观要素分离化以防范风险,刑法应扩张以强化民众的安全感。^① 风险刑法理论提出了刑法规制社会的新课题,反映了现代社会的集体焦虑,契合了客观存在的立法现象,^②具有一定的理论优势。但也有学者认为,“无限制扩充国家权力来抵御社会风险就是最大的风险。刑法应对风险绝对不是通过确立风险刑法的模式来强调刑法的恐吓性。”^③ “政策导向的刑法蕴含着摧毁自由的巨大危险。有必要借助刑事责任基本原则对风险刑法进行规范与制约,合理处理原则与例外的关系。”^④ 有学者基于对风险刑法理论的担忧,对在实践中出现的环境犯罪治理早期化的呼声提出了明确反对,认为“对积极一般预防的过度依赖以及生态中心主义环境法益观的脱离现实,决定了以之为据的环境犯罪治理的早期化欠缺合理性”。^⑤

风险社会较客观地展示了人们对现代社会的主观感受。“虽然风险控制技术存在,但不安全感普遍弥漫。风险的发生、分配与预防,而非财富的生产和分配,已经成为风险社会的主要关注问题。”^⑥ 风险社会所言之风险,更多意义上表明了人们对社会生活中某些领域尤其是公共领域安全度降低的忧虑。风险社会所言之风险的控制需要复杂的系统,政府规制成为必然,但并不必然带来法律的扩张与强制力的滥用,“除非法律作出了相反的要求,对风险规制的司法审查应当要求规制机构在对成本和收益都作出合情合理的评估的基础上,证明规制措施能够带来超过成本的好处。”^⑦ 风险客观存在,但并不必然转化为危险。^⑧ 刑法机制的有限性决定了刑法只能调整与部分控制那些可类型化、可测量的风险,因此某些群体应对环境污染的恐惧或焦虑而希望刑法介入的期待并不科学。

对环境犯罪治理早期化持反对意见的思维前提是,污染环境犯罪所侵害的客体是传统法益,对尚无侵害或者具体威胁到传统法益的行为进行犯罪化处理,相较于

① 参见齐文远:《刑法应对社会风险之有所为与有所不为》,《法商研究》2011年第4期。

② 于志刚:《“风险刑法”不可行》,《法商研究》2011年第4期。

③ 孙万怀:《风险刑法的现实风险与控制》,《法律科学》2013年第6期。

④ 劳东燕:《公共政策与风险社会的刑法》,《中国社会科学》2007年第3期。

⑤ 刘艳红:《环境犯罪刑事治理早期化之反对》,《政治与法律》2015年第7期。

⑥ 珍妮·斯蒂尔:《风险与法律理论》,韩永强译,北京:中国政法大学出版社,2012年,第53页。

⑦ 凯斯·R. 孙斯坦:《风险与理性——安全、法律及环境》,师帅译,北京:中国政法大学出版社,2005年,第137页。

⑧ 正是在这个意义上,有论者认为,“风险存在于社会生活的所有方面,不可能预防全部的风险。预防原则应当进行重构,代之以灾难预防原则,即对重大危险进行预防,并在政策和法律制定过程中注意相关法律措施的成本。”(参见凯斯·R. 桑斯坦:《恐惧的规则——超越预防原则》,王爱民译,北京:北京大学出版社,2011年,封底)

传统刑法确定罪名的方式而言,表现为早期化。也有论者基于对环境犯罪所侵害实质客体的不同理解,而对上述环境犯罪早期化的反对表达了反对,认为污染环境罪是情节犯,环境安全本身即为其保护法益,该罪的立法与司法充分体现了法益保护的早期化。法益保护早期化并非建构于风险刑法理论之上,能够有效治理污染环境犯罪;污染环境罪法益保护的早期化以生态学的人类中心主义法益观为依据,不存在消解法益概念的问题;刑法谦抑主义不等于绝对地反对犯罪化,污染环境罪法益保护的早期化兼顾了人权保障,符合谦抑性的要求。^①还有学者认为,污染环境罪所保护的法益是环境本身;严重污染环境既是对放射性、传染性、毒害性程度的要求,也是对排放、倾倒、处置行为本身的限定,因而污染环境罪属于行为犯、准抽象危险犯。^②

产生上述分歧的主要原因在于,不同学者对污染环境或者破坏生态等典型的环境犯罪行为所具有的法益侵害性的理解存在差异。若坚守传统刑法理论中行为必须侵害到具体法益或者对具体法益形成现实危险的判断标准,则仅可将部分危害行为作入罪化处理;但若将生态环境本身或者环境安全等作为侵害客体,则在上述情形下,行为已然具有法益侵害性,可以构成犯罪。上述分歧的焦点是:风险社会理论所言之风险是抽象的一般风险,还是在具体领域(如交通安全、食品药品安全、生态环境安全、国家安全)具体情境之下可以类型化且可度量的具体危险。若秉持风险社会中的一般风险是抽象的,依据刑法调整机制,则从技术上不适合纳入刑法调整;若秉承后者,从刑事立法的科学性与技术上,若风险领域的风险可类型化、可具体化、可度量化,则此种风险可以转化为刑法上的具体危险而纳入刑法调整。^③

(三) 生态文明保障的刑法机制与社会危害性理论

长期以来,社会危害性理论是我国刑法理论中占据主流的学说或理论,社会危害性在相当长的时期内是犯罪概念的重要组成部分。在“犯罪是具有社会危害性,违反刑法并应接受刑法处罚的行为”的犯罪概念中,社会危害性成为判断是否成立犯罪的实质标准,污染环境或破坏生态等行为是否入罪及类罪区分等问题也将接受社会危害性理论的检验。

① 参见黄旭巍:《污染环境罪法益保护早期化之展开——兼与刘艳红教授商榷》,《法学》2016年第7期。

② 参见陈洪兵:《解释论视野下的污染环境罪》,《政治与法律》2015年第7期。

③ 《刑法修正案(八)》、《刑法修正案(九)》体现了将抽象风险转化为具体危险的途径,并通过刑事立法或司法解释,将这种危险与行政法上的标准关联,如危险驾驶罪、污染环境罪等。

进入 21 世纪以来,社会危害性理论虽受到刑法学界内部的反思或批判,^①但也得到相当程度的坚持与坚守。^②笔者认为,以社会危害性理论为核心的犯罪概念,对于传统犯罪的解释令人信服,这是因为对危害国家安全犯罪、危害公共安全犯罪、侵害公私财产犯罪、侵害公民人身或自由犯罪等传统犯罪,国家与公民对其社会危害性的判断并无本质差异。在上述犯罪中,行为的社会危害性恰恰是行为侵害国家法益、社会法益与公民人身法益、财产法益等的刑法表达。在上述领域,社会危害性理论与法益理论在本质上是相通的,两者倡导下的刑法观皆为实质刑法观,^③实现了与既有法治体系、法治价值的连接。

但也要看到,由于刑法在整体法治体系中具有一定保守性,当国家与国民对社会价值的认知不能同一时,社会危害性理论主导下对相关行为是否构成犯罪以及罪轻罪重的判断,可能与大众认知产生偏离。^④上述偏离存在两种倾向:其一,公众认为社会危害性较为严重之行为,在既有刑事立法或刑事司法度量之下其定罪量刑不能满足公众期待,如绝大多数污染环境行为虽被定罪,但其刑期均在 3 年以下;其二,公众认为社会危害性不大的行为,在既有刑事立法与刑事司法度量之下,公众却认为对此类行为之刑事处罚过于严厉,例如河南大学生掏鸟窝案(以下简称“掏鸟窝案”)。^⑤

在生态环境领域的刑法与犯罪问题上,社会危害性理论遇到的解释困境的深层次原因是:国家与公民、公民与公民之间在生态环境领域的认知或利益存在差异。首先,在认知层面上存在差异。如国家基于保护珍贵、濒危野生动物,而对非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物配置了较高刑罚,而不同素质的公民对于珍贵、濒危野生动物所具有的生态价值的认知存在差异,所以不能很好地将掏鸟窝这种外观上

① 参见陈兴良:《社会危害性理论——一个反思性检讨》,《法学研究》2000 年第 1 期;陈兴良:《社会危害性理论:进一步的批判性清理》,《中国法学》2006 年第 4 期;樊文:《罪刑法定与社会危害性的冲突——兼析新刑法第 13 条关于犯罪的概念》,《法律科学》1998 年第 1 期;等等。

② 参见储槐植、张永红:《善待社会危害性观念——从我国刑法第 13 条但书说起》,《法学研究》2002 年第 3 期;利子平、石聚航:《传统法律文化:解读社会危害性的新路径》,《法制与社会发展》2010 年第 4 期;赵秉志、陈志军:《社会危害性理论之当代中国命运》,《法学家》2011 年第 6 期;等等。

③ 参见刘艳红:《实质刑法观》,北京:中国人民大学出版社,2009 年;魏东:《保守的实质刑法观与现代刑事政策立场》,北京:中国民主法制出版社,2011 年。

④ 认知产生偏离将导致刑法的公众认同问题。有学者认为,公众对刑法的认同中,对生活利益的重要性的认识具有重要意义。(参见周光权:《论刑法的公众认同》,《中国法学》2003 年第 1 期)

⑤ 参见《大学生掏鸟案细节:曾网上发布买卖鹰隼信息》,2015 年 12 月 4 日, <http://news.sohu.com/20151204/n429791351.shtml>, 2017 年 4 月 13 日。



貌似具有正当性的行为与既有刑法评价实现有效关联,导致对这类行为的罪感薄弱、恶感缺失。其次,在利益层面上存在差异。在生态文明早期阶段,因为秉持人类中心主义,多数人认为从大自然获取财产利益或生态利益天经地义,无需支付对价,因此对刑法将非法狩猎行为、非法捕捞行为、盗伐林木行为、污染环境行为等作入罪化处理持一定的质疑,对于重判重罚甚至会表现出抵制情绪。^①

由上述分析可知,社会危害性理论对于类似生态法益这样的新型法益的识别与度量能力是有限的。掏鸟窝案这样的典型案件也使我们再次认识到,社会危害性理论中所包含的社会危害需在个案或类罪中得到具体解释,并与整体法治秩序所保护的价值实现贯通与连接,方可能使刑法在日益变动的社会中不至于为社会所诟病,也才有利于在维护公民自由的基础上,实现对相关主体权益的及时有效保护。

三、生态文明保障的刑事立法机制

刑事立法是刑法机制发动的首要程序。生态文明保障的刑事立法机制,是指为保障生态文明建设,国家在生态环境领域制定刑事法律规范的基本方法、基本程序与基本路径。由于生态环境领域具有一定的特殊性,在该领域进行刑事立法需将刑法机制与生态环境领域的相关规律实现有机结合,努力提升刑事立法的科学性,方可使预设的刑法功能得到最大限度的实现。

(一) 生态环境领域刑事立法的科学基础

首先,应注重刑法多元机能的协调配置。社会统制虽是刑法的本质机能,^②也是刑法机制的逻辑起点,但对于实现刑法目的而言,尚需将刑法的具体机能,即维持秩序机能、保护法益机能、保障人权功能与刑事立法结合起来。按照上述逻辑,在对某一领域进行刑事立法时,需综合考量该立法在维持秩序、保护法益、保障人权三者之间的时空关系与功能配置。

由于生态环境领域具有较为强烈的公共性,在近代以来成为政府规制的重要标的。^③

① 导致此类情形出现的原因除与国家所处的生态文明发展阶段有关外,与国家在自然资源领域的产权制度也有直接关联。我国实行自然资源国家所有制,对自然资源的非法侵害,既侵害到自然资源所具有的生态价值,也侵害到国家对自然资源的所有权,这是我国刑法对侵害资源类犯罪配置较严厉刑罚的原因之一。(参见焦艳鹏:《自然资源的多元价值与国家所有的法律实现——对宪法第9条的体系性解读》,《法制与社会发展》2017年第1期)

② 参见马克昌:《刑法的机能新论》,《人民检察》2009年第8期。

③ 政府为追求秩序进行的规制,除建立基于日常管护式的行政管理外,还包括对医疗健康、环境安全、交通安全等领域实行的风险管理。(参见史蒂芬·布雷耶:《打破恶性循环——政府如何有效规制风险》,宋华琳译,北京:法律出版社,2009年)



规制的首要目的在于维持秩序,这也成为刑法介入生态环境领域的主要理据,但需注意的是,由规制而生之秩序维护机能仅为刑法的机能之一,若刑法只追求秩序维护,则与行政法无异,此种情形下容易出现过罪化,^①使刑法具有侵害自由的危险。

生态环境领域的刑事立法在设置维持秩序机能之外,尚需对保护法益与保障人权作相关设置。我国《刑法》第六章第六节以“破坏环境资源保护罪”为名,并居于“妨害社会管理秩序罪”之下的立法体例表明,在立法者的观念中,此类犯罪所保护的客体是社会管理秩序,这部分立法首先或主要应承载刑法维持秩序的机能。此种立法理念具有一定的时代背景,但也值得反思。掏鸟窝案发生后,媒体报道多地发生类似案件。^②司法机关对上述案件的判决是依据刑法依法裁判的,但公众对此类案件的刑罚提出质疑也值得思考,若仅以行为违反国家相关法律、法规而以妨碍社会管理秩序作为定罪依据,而不对上述刑法所侵害的具体法益向当事人及社会作出解释,刑法的社会接受度将有降低的风险。

刑事立法尤其是对包括生态环境领域在内的公共领域的刑事立法,需考虑刑法多重机能的体系配置。以单一刑法机能尤其是仅以秩序维护机能为价值追求的刑事立法,不仅存在刑法规范社会接受度降低的风险,也可能带来刑事司法中法官出于对整体秩序价值的维护而进行定罪预设基础上有罪推定风险的加大,并可能忽略个案中危害行为对具体法益侵害程度的判断,从而对精细化司法形成干扰。

其次,需将自然资源载体的生态价值法益化。保护法益是刑法承载维持秩序之外的另一重要机能,是指刑法规范以犯罪为条件对之规定作为法的效果的刑罚,保护由于犯罪遭受侵害或威胁的价值或利益的机能。^③一些学者认为当前刑法在生态环境保护方面存在法益保护前置化现象,这种观点的本质是不承认生态环境领域存在独立的法益类型,具有局限性。生态环境具有生态价值已被环境科学所证明,并已逐步具备测量技术与方法。^④如果将污染环境、破坏生态的行为所造成的法益侵害仅仅设置为传统刑法所保护的法益类型,则刑法对上述行为所具有的危害性归纳是不完整的,进而影响刑法功能的实现。

现代科学研究表明,大自然既对人类提供诸如林木、矿物、食物等直接供人类

① 过罪化是指“国家制定太多刑法,把很多不需要或不应当作犯罪进行处理的行为当作犯罪进行了处理,导致国家刑罚权过度扩张”。(参见道格拉斯·胡萨克:《过罪化及刑法的限制》,姜敏译,北京:中国法制出版社,2015年,第374页)

② 参见《逮了1689只壁虎,6人被判有罪》,《大河报》2014年12月22日,第A13版;《逮20000多只青蛙8人被判刑》,《都市晨报》2016年8月19日,第A16版。

③ 马克昌:《刑法的机能新论》,《人民检察》2009年第8期。

④ 环境保护部于2016年6月印发《生态环境损害鉴定评估技术指南 总纲》和《生态环境损害鉴定评估技术指南 损害调查》,表明我国已初步建立对生态环境损害进行测量的方法与技术进行规范的制度。(参见 http://www.zhb.gov.cn/gkml/hbb/bgt/201607/t20160705_357139.htm,2017年2月12日)

生产或生活使用的物品,也具有提供调节气候、消化污染、防风固沙、涵养水源、减轻灾害等的生态系统服务功能。^①这表明大自然在具有财产价值的同时,又具有产出生态功能的生态价值。在生态文明时代,作为现代法治核心目的的人,对大自然的需求已超越物质层面,具有生态层面的向度。比如矿藏储存于地壳并与地壳形成整体,其本身可能不具有什么生态价值,但其被储存的状态则可能具有生态价值,若对其进行不当采掘,则可能破坏其生态功能。

我国《刑法》第六章第六节“破坏环境资源保护罪”对环境资源的经济价值保护较为完整,但对环境资源的生态价值的保护力度则有待提升。比如盗伐林木罪,定罪量刑以盗伐林木的数量为主要标准,而对林木所具有的生态价值不作具体考量。^②大气、水体、土壤作为生态环境的构成要素,其生态价值不言而喻,承载林木、野生动植物、矿产资源等自然资源的土地、林地、草地、江河湖泊、海洋、滩涂等在蓄积上述具有经济价值的自然资源之外尚具有生态价值。在对自然资源的经济价值进行刑法保护之外,尚需对自然资源载体的生态价值进行刑法保护。

自然资源载体生态价值的法益化,其本质是在刑事立法过程中将自然资源载体的生态价值作为刑法保护的客体,并将上述生态价值的保护作为刑法的重要机能。自然资源载体生态价值的法益化,是生态文明保障的刑事立法机制的重要构成。实现上述立法理念的关键在于将自然资源与自然资源的载体在刑法上作明确区分,包括耕地、野生动植物、林木、矿产资源在内的自然资源在我国刑法中已成为被保护客体,并建立其经济价值的测量体系,但作为自然资源载体的土地、林地、草地、江河湖泊、海洋、滩涂等的生态价值却没有成为刑法保护的客体,也没有建立起测量体系,这是我国生态文明保障的刑事立法机制必须突破的障碍。

(二) 生态环境领域刑事立法的技术路径

首先,归纳生态环境领域应受刑法保护的法益。生态环境领域应受刑法保护法益归纳的核心是,对作为刑法价值主体的人在生态环境领域的利益需求及其样态进行归纳。从整体主义视角而言,可以将人在生态环境领域的利益归纳为人的生态法益,但基于刑事立法的科学性及罪刑法定原则的要求,在刑事立法中设置罪名,尚需对人的生态法益的内部结构进行分析。

人的生态法益主要包括积极的生态法益与消极的生态法益两类:前者是指人或人类主动追求的以生态环境资源为利用对象的法益,主要是指人对生态环境的直接

① 生态系统服务是指地球生态系统向人类提供的生态功能。(参见高敏:《“生态系统服务”与“环境服务”法律概念辨析》,《武汉理工大学学报》2011年第1期)

② 我国刑法所规定的盗伐林木罪,对盗与伐两种行为进行了混同评价。需要注意的是,盗侵害的客体应为财产法益,伐(客观上使林木死亡)侵害的实质客体为林木的生态价值。

利用（如呼吸空气、饮用水源等），包括从自然环境中获取各类自然资源供生活或生产使用，在自然环境中休憩、旅游等；后者是指因生态环境或自然资源被破坏，而使人的传统法益（财产法益、人身法益等）受到侵害或侵害的具体危险，如因环境污染而使得人的身体健康、具有产权的财产（如养殖的水产品、种植的农作物等）受到侵害、损失或损害。消极的生态法益并非人或者人类所直接追求，而是人或者人类为维护自身的传统法益免遭来自因生态环境破坏而建立的防御性法益。

在传统刑法理论中，消极的生态法益难以成为刑法保护对象。其主要原因在于，与传统法益相比，此种消极法益较难实现类型化，且无法实现较好的度量。在上述理论模型下，对生态环境领域进行刑法保护的立法模式的可能选择，即所谓法益保护前置化，将侵害消极生态法益的行为设置为危险犯。

生态文明建设过程中，刑法对积极的生态法益的保护模式正在逐步生成。在权利意识或权利观念的塑造下，积极的生态法益往往被环境法学者代称为环境权利，而成为或可能成为法律保护的标的。刑法对积极的生态法益的保护应以刑法机制为限，即刑法作为整个法秩序的保护法，需以生态法益实在法秩序^①的存在为发动前提，也正是在此意义上，德日学者认为环境刑法具有强烈的行政从属性。^②当然，对积极的生态法益进行刑法保护，除了要实现行政管理秩序的维护之外，尚需对积极的生态法益的本身进行刑法描述与具体识别，建立起法益保护与人权保障之间的关联。^③

其次，对侵害人的生态法益的行为进行类型化。刑法是规制人的行为的法律科学。对侵害或威胁法益的行为进行类型化，并将之确定为犯罪行为进行惩治，是刑事立法的基本路径。遵循上述路径，在环境刑事立法过程中，需对侵害或威胁人的生态法益的行为类型化，从而使该类行为成为刑法所规制的行为。

侵害行为的类型化，主要应依据实践进行归纳。如《刑法》第 338 条“污染环境罪”的规定中关于危害行为的描述是“违反国家规定，非法排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质，严重污染环境的”，此种立法例即达到对危害行为进行类型化的区分：“非法排放、倾倒、处置”

① 此处的实在法秩序，是指除刑法之外的民法、行政法等各部门法所建立起的现实世界实在运行的法律秩序。（参见冯军：《刑法的规范化诠释》，《法商研究》2005 年第 6 期）

② 行政从属性是指在行政犯罪中，刑法所保护的法律关系从属于行政性法律关系。（参见庄乾龙：《环境刑法定性之行政从属性——兼评〈两高关于污染环境犯罪解释〉》，《中国地质大学学报》2015 年第 4 期）

③ 法益保护与人权保障的连接点在于作为法律核心主体的人的权利，即刑法的法益保护机能与人权保障机能的连接点在于人的法定权利，因此对法益进行实质解释的主要工具在于人的法定权利，也即法益的实质内容可由法定权利填充，这是对刑法所要保护的法益进行解释时所应循的路径。



表明污染环境行为在实践中具有典型的三种类型；“有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质”表明上述行为之下必须有污染环境的物质介入生态环境，并对危害物质进行了类型化。

相比于污染环境罪的刑事立法，我国现有其他环境资源犯罪的刑法规范，在立法技术上还存在提升与优化的空间。如前文提及的“非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪”对危害行为的描述为“非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的”，虽然此规范表明立法对此罪名的行为类型进行了基本区分，但由于猎捕与杀害两类行为在实践中存在杀害式猎捕与猎捕后杀害等诸多关联情形，且珍贵与濒危是公众较难有明确认知的词汇，相关司法解释也并未对珍贵与濒危作出明确解释，而是采取直接转化为野生动物名录的方式，^① 这也是在实践中诸多判决不能得到公众足够认同的原因之一。

刑事立法若仅对实践中的违法事实进行类型归纳，而对危害行为本身可能呈现的样态不进行类型化，将导致刑法规范不明确，从而给刑法的公众认知与刑事司法带来困扰。“刑法规范既要按照罪刑法定原则的要求保持基本的明确性，又不得不保持一定的张力以适应社会生活的需要，这就要求其必须具有一定的概括性。”^② 刑法语言的概括过程，既是对危害行为进行类型化与具体化的过程，也是对危害行为所侵害或威胁的法益类型化与具体化的过程。这种类型化与具体化的思维应贯穿于生态环境刑事立法的全过程。

最后，对类型化的生态法益建立可测量的标准。法益的可测量化是刑法法益从立法走向司法的连接点，也是避免法益精神化的控制机制。法益的可测量化在传统刑法领域体现为法益向权利的转化与危害结果的相当性判断。关于法益向权利的转化，主要表现为当犯罪行为所侵害的客体为传统的财产法益或人身法益时，刑事立法或相关的司法解释建立了基于财产权或人身权的定罪量刑的标准，定罪量刑的标准与转化为数量标准的权利规模呈正相关关系。当危害行为或危害后果难以实现向公民权利特别是民事权利的转化时，刑法则采取公民与国家尽量都能接受的惩罚方式，以使刑事处罚与社会公众的接受程度具有相当性。这种相当性的判断在危害国家安全、危害公共安全等非财产法益、非人身法益的公法法益中大量存在。

对生态法益建立可测量的标准也可依如上两条路径：第一，将污染环境、破坏生态等危害行为所侵害的传统法益转化为数量标准。第二，将污染环境、破坏生态等危害行为所侵害的非传统法益建立与其危害具有相当性的转化标准，并建立与刑

① 参见《最高人民法院关于审理破坏野生动物资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条。

② 付立庆：《论刑法用语的明确性与概括性——从刑事立法技术的角度切入》，《法律科学》2013年第2期。



法典中危害性质、危害后果相关的罪名比照体系。^① 依据上述两条路径,生态环境领域的刑事立法,需综合考量行为的危害性,并建立与行为危害性相当的可供司法裁量的生态法益侵害标准。上述标准又可区分为定罪标准与量刑标准。定罪标准需区分罪与非罪的边界,即实现对一般行政违法与刑事违法的区分;量刑标准则为超过定罪标准之后法益侵害程度的度量标准,即确定罪轻、罪重的标准。

生态法益测量标准体系的建立对生态法益的测量技术具有一定的依赖。污染环境、破坏生态等行为往往造成自然生态或环境要素的破坏,从而成为民事领域权利救济请求的标的。对生态环境损害的程度进行测量,不仅对于民事赔偿具有法律意义,对危害行为的刑法评价亦有法律意义。具有一定公允性的生态环境损害测量方法,近年来逐步被引入环境侵权民事领域的裁判之中,这对于在刑事立法中建立生态法益的测量标准具有重要参照价值。

四、生态文明保障的刑事司法机制

刑事司法作为微观的法律适用活动,是刑法发挥作用机理的重要构成。生态文明保障的刑事司法机制,是指为保障生态文明建设,司法机关依据刑事立法,对具象的法律事实进行比照,进行刑法评价的活动。

在环境刑事司法活动中,对危害行为所造成结果的判断是其重心,其本质是对危害行为侵害法益程度的判断。下面通过三起典型环境刑事案件讨论其中的利益衡量和法益判定问题,并尝试对我国生态文明保障的刑事司法机制构建中的难题提供破解之途。

(一) 昆明“牛奶河”水污染案:危害行为形态作为入罪标准后是否还需测量生态损害

昆明“牛奶河”水污染案(以下简称“昆明案”)是2013年发生在云南昆明市的一起水污染刑事案件。云南省昆明市东川区是铜矿开采区,该区长期以来存在大量采矿、选矿企业。2013年有媒体报道,该区境内的小江因水体污染,河水呈乳白色,故将该河称为“牛奶河”。媒体报道引发社会公众对该环境污染问题的广泛关注,随后司法机关介入,最终三家企业及其相关人员被刑事处罚。在该案刑事判决中,法院对上述三家企业污染环境行为的入罪判断均采用相关司法解释^②诸多入罪

① 此种转化方式在我国刑事立法中已有先例。如《刑法》第125条在规定“非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪”时,将其与“非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪”进行了相当性比较,使得危险物质危害公共安全的相关犯罪与枪支、弹药、爆炸物危害公共安全的相关犯罪的社会危害性具有了测量上的类比性。

② 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释[2013]15号)。

标准中的一条,即“两年内曾因违反国家规定,排放有毒物质受过两次以上行政处罚,又实施前列行为的”。该案被告人最终被判处3个月至1年3个月不等的有期徒刑及一定数额的罚金。

在上述案件中,法院在对被告人进行定罪量刑时,对危害行为的形态(即排放了何种物质;是否利用暗管、渗井、渗坑等;是否两年内因同一事实第三次行政违法等)进行了司法调查与确认,并据此作出构成犯罪的刑法评价。这引发一个问题,即在污染环境刑事案件的司法判定中,若危害行为的形态符合相关司法解释确立的人罪方式,^①在作出有罪判定之后,是否可以不再考虑危害行为的危害后果(即生态环境损害的后果)?

答案是否定的。环境刑事司法中若仅依危害行为的形态进行定罪量刑,显然不符合刑事诉讼法中事实清楚的标准。刑事案件中的犯罪事实不仅包括危害行为,还包括危害结果。即便仅依危害行为的形态即可入罪,但显然不构成案件的全部事实。下表是2012—2016年全国2340件污染环境刑事案件入罪方式的统计:^②

表1 2012—2016年全国污染环境犯罪入罪方式统计

类型	数量(件)	占比(%)
排放重金属物质超标3倍以上	1631	69.70
非法处置危险废物3吨以上	561	23.97
其他类型	148	6.33
总计	2340	100

从上表可以看出,2012—2016年全国2340件可查询到裁判文书的污染环境刑事案件中有69.70%的以排放重金属物质超标3倍以上,23.97%的以非法处置危险废物3吨以上进行了入罪判断,两者合计达到93.67%。需要说明的是,上述“排放重金属物质超标3倍以上”、“非法处置危险废物3吨以上”皆在2013年第15号

① 即《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释[2013]15号)规定的五种情形:在饮用水水源一级保护区、自然保护区核心区排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质的;非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的;非法排放含重金属、持久性有机污染物等严重危害环境、损害人体健康的污染物超过国家污染物排放标准或者省、自治区、直辖市人民政府根据法律授权制定的污染物排放标准三倍以上的;私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质的;两年内曾因违反国家规定,排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质受过两次以上行政处罚,又实施前列行为的。

② 本表及表2依据中国裁判文书网中相关司法文书经提取有效信息整理统计而成。本人指导的硕士研究生廖顺、李彬承担了上述信息的提取与整理工作,特表谢忱。

司法解释所确定的 14 种污染环境犯罪入罪方式中，且属于对污染环境危害行为形态的描述。

再来分析同期上述 2340 件污染环境刑事案件有期徒刑配置情况的统计：

表 2 2012—2016 年全国污染环境犯罪有期徒刑适用情况统计

刑期区间	数量（人）	占比（%）	刑期区间	数量（人）	占比（%）
半年以下	448	10.91	2 年到 2 年半	143	3.48
半年到 1 年	2066	50.30	2 年半到 3 年	34	0.83
1 年到 1 年半	1060	25.81	3 年到 5 年	54	1.31
1 年半到 2 年	302	7.35	5 年以上	0	0

统计显示：在有期徒刑的配置上，刑期半年以下的为 448 人，占全部被判刑人的 10.91%；刑期半年到 1 年的达到 2066 人，占 50.30%；刑期 1 年到 1 年半的为 1060 人，占 25.81%；三者合计占比为 87.02%。上述数据表明，2012—2016 年全国污染环境罪刑事案件中，绝大多数的被告人被处以 1 年半以下的有期徒刑。就《刑法》第 338 条为污染环境罪所配置的两档刑期（3 年以下、3 年以上 7 年以下）而言，上述刑期是相当轻的。

87.02% 的污染环境罪刑事被告人被轻判，93.67% 的污染环境罪属于依据行为样态判定入罪。虽然不能认为两者之间存在对应式的必然联系，但表明：若仅对污染环境罪的行为形态进行刑法评价，而不对危害行为所造成的后果进行刑法评价，必然带来“定罪成功，量刑失败”的司法样态，这显然不符合刑事立法目的。

罪刑均衡、罪责刑相适应是刑法的基本原则。全国范围内的污染环境罪刑事案件造成的危害后果有轻有重，不可能完全一致，虽然刑罚配置要考虑多种因素，但也不应出现太过明显的刑期趋同。若仅依或主要依据行为形态对污染环境罪进行刑法评价，则会使得刑事处罚出现类似行政处罚的效果，从而削弱刑法的功能。

（二）泰州 1.6 亿元污染环境案：虚拟治理成本法可否作为危害后果的判断方法

在环境刑事司法中，仅依据危害行为的行为形态进行刑法评价是不全面的，应在事实清楚的指引下对危害行为的危害后果进行刑法评价。需进一步考量的还有，环境刑事司法中哪些危害后果可以引入刑法评价以及如何评价，下面以泰州 1.6 亿元污染环境案（以下简称“泰州案”）作相关讨论。

泰州案是基于同一事实的数个案件、数个判决的合称，包括刑事案件与民事案件两部分。其中民事部分属于环境公益诉讼案件。基本事实如下：2012 年 1 月至 2013 年 2 月，位于江苏泰州市的 6 家公司将生产过程中产生的危险废物废盐酸、废硫酸总计 2.5 万余吨，以每吨 20—100 元不等的价格，交给无危险废物处理资质的



企业偷排进泰兴市如泰运河、泰州市高港区古马干河中，造成水体污染。

该案件的刑事部分先于民事部分被判处。“2014年8月，泰州泰兴市人民法院以环境污染罪判处涉案的14人有期徒刑二至五年不等，并处罚金16万至41万元。随后，泰州市环保联合会又以公益组织身份，向江苏省泰州市中级人民法院提起环保公益诉讼。泰州市中级人民法院一审判决，常隆等6家公司在判决生效后9个月内赔偿环境修复费用共计160666745.11元，并在判决生效后十日内给付泰州市环保联合会已支付的鉴定评估费用10万元。常隆等公司不服一审判决，上诉至江苏省高院。12月30日，江苏省高院终审判决，维持一审判决的赔偿数额部分，要求6家公司于本判决生效之日起30日内将赔偿款项支付至泰州市环保公益金专用账户。”^①

案件的刑事判决部分并没有考量水体被污染的实际损害，但在民事判决部分法院支持了原告提出的1.6亿余元的环境修复费用。有信息表明，上述排放行为发生后，由于江河水具有流动性，被污染河流的水质恢复了原初状态，当地环保部门并没有对水体进行环境修复，也没有发生相关费用。司法文书显示，上述1.6亿元的环境修复费用是依据虚拟成本治理法^②计算出来的。虚拟成本治理法作为环保部推荐的环境污染损害鉴定评估方法，自有其科学性。但依据此种方法计算出的环境修复费用可否作为环境刑事案件中的危害后果进行刑法评价？2013年第15号司法解释将“造成公私财产损失30万元以上的”作为污染环境罪的人罪标准之一，并将“造成公私财产损失100万元以上的”作为污染环境罪中情节严重的标准从而适用第二档刑期（即3年以上7年以下），若“泰州案”刑事部分将上述1.6亿元作为定罪与量刑标准，是否合理？

虚拟成本治理法是对生态环境采取虚拟治理而产生的成本的计算方法，也就是说在客观上并没有环境修复行为，因此不能将虚拟成本治理法计算出的数额作为已经产生的财产损失的数额，所以在污染环境行为的刑法评价中，不能将其直接等价于传统的财产法益被侵害的数额，不能直接将虚拟成本治理法计算出的环境修复费用作为2013年第15号司法解释中定罪量刑的公私财产的数额。

虚拟成本治理法既是环境修复费用的核算方法之一，也是对生态损害评估具有操作意义的方法之一。环境被污染、生态被破坏之后，无论是否进行修复，其损害是客观的。上述损害如何纳入刑法评价，既与评价方法相关，也与刑法的理念、原

① 《江苏6家化工企业非法处置废酸被判赔环境修复费1.6亿元》，2014年12月30日，http://news.xinhuanet.com/fortune/2014-12/30/c_1113833364.htm，2016年7月30日。

② 环境保护部《关于开展环境污染损害鉴定评估工作的若干意见》中环境污染损害数额计算的推荐方法，是指采取虚拟治理成本乘以一定系数从而来确定环境修复成本的方法。（参见《连云港一起环境污染案判决 污染者被判960小时环境公益劳动》，《中国环境报》2015年6月24日，第5版）



则、机制等相关。在污染环境犯罪领域,行为人往往持间接故意^①的心理态度,对危害结果的发生往往仅具有概括意义上的放任,而对危害造成的生态损害往往没有能力判断,因此以刑法学的主客观相一致原则衡量,虚拟成本治理法评价出的环境修复费用在定罪量刑时不宜直接适用,但可以作为定罪与量刑的参考。

(三) 河南大学生掏鸟窝案:数量标准可否直接作为生态法益侵害的实际后果

环境刑事司法中既不能不对生态环境损害的事实进行刑法评价,又不能直接将基于虚拟治理而计算出的生态损害赔偿数额直接导入刑法评价,那究竟应如何对环境刑事司法之中生态法益侵害的状况进行评价呢?我们可以“掏鸟窝案”为例,再作进一步的讨论。

本案基本事实是:家住河南省新乡市辉县的一名大学生,从树上掏得燕隼 12 只并在网上出售,后被刑事拘留并以非法猎捕珍贵、濒危野生动物罪而刑事处罚。^②该案引起社会关注与讨论的焦点在于案件的量刑。社会公众普遍认为,掏鸟窝具有一定的普遍性,不少居住在农村的人年少时都做过,是一定群体的集体记忆;虽然从鸟窝里掏得的燕隼是国家二级保护动物,且达 12 只,但判处 10 年 6 个月的徒刑太重;部分公众与刑法学者对该案是否构成犯罪也提出了批评。^③

该案一、二审法院的判决是有刑法依据的。燕隼属国家二级保护动物,依据相关司法解释,非法猎捕燕隼 10 只以上即构成刑法第 341 条“非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪”中的“情节特别严重”的情形而应处 10 年以上有期徒刑。该案的焦点在于:法院对破坏环境资源的刑事案件进行裁量时,除了依据相关司法解释确立的数量标准进行定罪量刑外,是否需对生态环境受到的实际损害进行判定?若实际损害与数量标准存在差异,法院可否进行选择?

-
- ① 关于污染环境罪犯罪构成中的主观要素,学界存在一定争议。笔者认为该罪的主观要素应为间接故意,即行为人对危害结果的主观心态为放任结果的发生。间接故意说基于对大量案例的提炼而成,在实践中基本没有发现涉嫌犯罪的企业或个人主动追求环境污染结果发生的情况,往往是对污染环境的后果可能发生具有一定的认知,但因追求经济利益而放任结果的发生。
- ② 该案二审维持了一审判决,案情可参见《大学生掏鸟案细节:曾网上发布买卖鹰隼信息》,2015 年 12 月 4 日, <http://news.sohu.com/20151204/n429791351.shtml>, 2017 年 4 月 13 日。
- ③ 对破坏生态行为的主观认知能力进行判定时,采取是否具备概括性认知的标准较为妥当,即行为人对破坏生态的行为对象的认知只需具有概括意义上的认知,即可认为具备刑法上的认识,而无需对行为对象具有精细化认知。换言之,在类似于掏鸟窝案中对行为人认知能力的判断上,只需对行为人是否认识到作为行为对象的鸟类与普通非保护鸟类具有差异性即可,而无需认知该鸟类的学名、种类归属、保护等级、生态价值等。概括性认知介于无认知与精细认知之间,是较为公允客观的认知能力判断标准。

将涉案野生动物的种类以及数量作为判断是否入罪及罪行轻重的标准，本质上是一种技术手段，即通过野生动物的种类或者数量衡量危害行为带来的危害后果，因此依据这种技术方法测量的法益具有拟制性。所以上述问题的实质是，在环境刑事司法中，对危害后果的判定，究竟是采实质判断还是拟制判断？

从刑法的精神与原理出发，无论何种犯罪，在可度量前提之下，均应对危害行为的危害后果进行探知。但考虑到法益度量的技术可行性及成本，对某些法益的度量可以转化为行政标准或数量标准，比如以野生动物的种类或数量来指代生态法益的损害程度，但考虑到实质公平，也不应排除辩方对生态法益实际受损程度的有理据辩护。上述实质与拟制的冲突可通过证明责任的分配得到一定程度的缓和，即检察机关在审查起诉与法庭公诉阶段，只需证明危害行为导致了刑事立法中拟制的后果，辩方对于上述指控可通过相关证据证明相关的种类或者数量所代表的生态环境利益与实际损失之间存在差异，审判机关可在上述检方指控的拟制的危害后果与辩方对实际损害的辩护之间进行衡量，据此对危害后果作出基于个案真实的判定。^①

上述典型案例的讨论表明，在生态文明保障的刑事司法机制中，需高度关注司法官在刑事司法活动中的利益衡量问题。利益衡量，“也称法益衡量，是指在法律所确认的利益之间发生相互冲突时，由法官对冲突的利益确定其轻重而进行的权衡与取舍活动”。^②作为一种司法方法，利益衡量揭示了法官适用法律的过程在一定程度上就是利益衡量的过程，但是，“利益衡量本质上是一种主观行为。正由于利益衡量的本质是一种主观行为，要增强它的妥当性和科学性，有必要从外部程序上去考察，要建立客观的科学的规则体系来完善它。”^③

增强环境刑事司法活动中利益衡量科学性的主要路径有：第一，通过刑事立法中不同法益的类型化设置，加强司法官对传统法益与生态法益的识别，将财产法益、人身法益、秩序法益与生态法益作为不同类型的法益纳入刑法司法评价；第二，通过庭审实质化等程序设置，增强刑事司法参与人对拟制法益与实质法益的辩论，增强司法官对不同类型法益大小的识别与度量；第三，降低技术证据法庭准入的门槛，在“排除合理怀疑”原则基础上，充分发挥技术证据的证明功能，提高对生态法益的度量能力，特别是对生态环境受损害程度，物种及生态要素等生态价值的评估加强司法判定。

需要注意的是，增强环境司法活动中法益衡量的科学性、实行精细化司法，不

① 以审判为中心的刑事诉讼制度改革对增强环境刑事司法活动的科学性具有积极意义。在该模式下，通过控辩双方的充分、有效辩护，可显著增进对当事人的行为样态、案件的事实情况，特别是生态法益实际受损情况的法庭认知，从而促进个案公正。

② 胡玉鸿：《关于“利益衡量”的几个法理问题》，《现代法学》2001年第4期。

③ 梁上上：《利益的层次结构与利益衡量的展开——兼评加藤一郎的利益衡量论》，《法学研究》2002年第1期。

能突破刑法的基本原则。“利益衡量只能在法律的疆界内发挥其应有的作用,不能超出法律的边界。而且,利益衡量应当与妥当的法律制度相联系,必须选择在一个妥当的法律制度中进行衡量。”^① 在环境刑事司法活动中,在加强对生态法益的识别与度量的过程中,刑法理论中的犯罪概念、刑法原则中的主客观相一致原则、谦抑性原则等仍然构成对法益衡量活动的外部约束。

五、生态文明保障刑法机制的法治系统

生态文明保障需要刑法机制,但由于法治具有系统性,刑法机制与其他法律机制作为法治系统中的关联要素,彼此之间既具有功能区分又具有价值连接,故尚需对生态文明保障刑法机制赖以产生功能的法治系统中的相关要素进行分析。下文将探讨生态文明保障的刑法机制与宪法、行政法、环境法等部门法机制的关系。

(一) 生态文明保障的刑法机制与宪法

宪法既是刑法的制定依据,也对刑法划定了调整边界。在法律价值上,刑法应传导宪法价值;在法律机制上,刑法应保障宪法的实施。

一是我国宪法为打击环境犯罪、维护社会秩序、保障人民权益提供了法律依据。《宪法》第 26 条规定,“国家保护和改善生活环境和生态环境,防治污染和其他公害”,这表明,我国宪法将保护环境、防治污染与公害作为了国家政策。为实现上述国家政策,国家成立生态环境管理机构,颁布相应的法律与行政法规,建立国家环境管理秩序。上述国家环境管理秩序构成我国刑法所保护的社会秩序。据此而言,《宪法》第 28 条规定的“国家维护社会秩序,镇压叛国和其他危害国家安全的犯罪活动,制裁危害社会治安、破坏社会主义经济和其他犯罪的活动,惩办和改造犯罪分子”中,包含为维护生态环境管理秩序而惩治和改造犯罪分子的内容。

运用刑法手段保护自然资源,在我国有明确的宪法依据。《宪法》第 9 条第 1 款规定:“矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源,都属于国家所有,即全民所有;由法律规定属于集体所有的森林和山岭、草原、荒地、滩涂除外”,此款明确了自然资源的国家所有权;该条第 2 款规定:“国家保障自然资源的合理利用,保护珍贵的动物和植物。禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏自然资源”。刑法作为宪法的保障法,将宪法明令禁止的行为纳入刑法调整顺理成章。

由上分析可知,从法治整体价值出发,我国刑法对生态环境、自然资源等的保护具有宪法依据。虽然 1982 年《宪法》颁行时,生态环境与自然资源在立法视角下

^① 梁上上:《利益衡量的界碑》,《政法论坛》2006 年第 5 期。



属于不同领域,但无论从国家经济制度还是国家义务的角度,国家具有保护环境、管理自然资源的职责是宪法所明确规定的。建立行政管理制度是落实宪法规范的主要方式,生态环境管理制度、自然资源管理制度都是国家制度体系的组成,其所保护的秩序形态构成宪法文本中所言的社会秩序,并成为我国刑法所保护的客体。

二是刑法对生态环境的保障应以不侵犯公民基本权利为限。平衡打击环境犯罪与保障人权的关系,应重视环境刑事政策的宪法化。“刑事政策的宪法化有助于消除刑事政策的模糊性,缓和其对实证法体系的冲击,补强其批判立法的功能。应该构建具有宪法关联性、以基本权利为核心的法益概念,使其兼具解释和批判立法的功能。”^① 循此逻辑,可以将宪法规定的公民的基本权利作生态主义维度的解释,将生态环境与公民的健康权、财产权、自由权等进行关联,逐步建立起内涵丰富的公民生态法益结构体系。在此基础上,将侵害公民生态法益的行为作犯罪评价时应对犯罪人的人权保障进行衡量从而进行制度设计与程序控制,使生态环境领域的刑事政策具有深厚的宪法基础。

(二) 生态文明保障的刑法机制与行政法

生态文明保障的刑法机制与行政法的关系集中体现在环境刑法的行政从属性上。具体而言,环境刑法的行政从属性主要包括环境犯罪成立要件上行政法标准的介入、环境司法过程中行政法标准的参与。

一是环境犯罪成立要件上行政标准的介入。环境犯罪成立需要行政标准的介入,是环境刑法在当代的重要特征。刑法学一般将含有这种特征的刑法条款或刑法条款的集合称之为行政刑法。环境犯罪成立与否的判定需引入行政标准,其本质是刑法与行政法在保护生态环境上基于其不同法律机制而进行的差异化配置。在现代法治体系之下,公共领域首先需要行政规制,而行政规制的重要机制即在于确定法律主体相关行为的行政违法性。在严密的法治体系之下,对相关法律主体违法性的判断,首先需进行行政违法性的判断,若行为不违反行政法,而直接进行刑法判断,并认为构成犯罪,是违反比例原则与法治精神的,因此在生态环境领域,具有刑法上违法性的前提是存在行政法上的违法性。以违法性程度衡量之,环境犯罪是严重违反行政法或具有严重的行政违法性而需承担刑事责任的行为。

二是环境刑事司法过程中行政法标准的参与。环境刑事司法过程中行政法标准的参与有其必然性。首先,从法益理论出发,法官定罪与量刑的思维过程,可以称之为法益识别与法益度量的过程。由于环境犯罪所侵害的客体主要为生态法益,而对于生态法益的识别与度量,往往需要引入行政法上的标准。其次,从精细化司法

^① 张翔:《刑法体系的合宪性调控——以“李斯特鸿沟”为视角》,《法学研究》2016年第4期。



角度而言,环境刑事司法过程中,对于危害结果的判断,在技术与成本允许的范围内,需对生态环境的损害程度进行合理测量,而这种测量往往需要环境管理上相关标准指导下的方法与技术。再次,依据刑法与行政法的一般关系,被判定为环境犯罪的违法行为应具有行政法与刑法的双重违法性,在此种情形下,行政法上的标准就成为环境犯罪司法判定的形式标准。

环境刑事司法过程中行政标准的参与须控制在一定限度之内。行政标准的参与在大多数情形下,其功能在于对危害后果的评估与评价,因此此种参与应在主客观相一致原则、罪责刑相一致原则等诸项原则的制约之下。在利用行政标准转化的入罪标准进行判定时,除考虑客观要素,还要考虑行为人主观方面是否表现为间接故意,两者结合方能实现定罪考察。罪责刑相一致原则在环境犯罪内的应用,主要表现为在对环境犯罪的罪过大小的判断上要超越传统犯罪,不能因为当事人的罪感缺失,或社会公众对这类犯罪的恶感不强,而在刑事司法过程中降低对其罪过大小的判断,而应以生态文明的发展进行动态考察,以法治实践引导社会公众对环境犯罪罪感与恶感的生成。

(三) 生态文明保障的刑法机制与环境法

生态文明保障的刑法机制还涉及与环境法的关系,主要涉及环境政策与刑事政策的关系、环境正义与刑事正义的耦合两个问题。

环境政策与刑事政策的关系是当前我国生态环境刑法保护领域必须厘清的问题。“风险社会的存在,决定了抽离政策的分析范式将无法真正认识现代刑法。”^① 环境政策与刑事政策,作为国家的公共政策,在形成机制上具有共通性,但在作用机理上具有差异。环境政策作为国家在一定时期内对生态环境是否需要保护以及保护到什么程度的基本态度,往往通过法律形式进行确认或转化。刑事政策是刑法学理论研究的向度之一,^② 但“刑事政策并非只是单纯的刑法问题,而是一个社会公共政策的问题”。^③ 刑事政策的作用机理一般是通过确立相应领域的刑事政策,进而制定相应的刑事立法,并带动刑事司法与刑事执行,从而实现对相关领域犯罪的惩治。^④

生态环境领域刑事政策的确立受到环境政策与刑事政策的双重影响。环境政策与刑事政策一致时,生态环境领域的犯罪惩治效果较好,反之则惩治效果较差。

① 劳东燕:《风险社会中的刑法:社会转型与刑法理论的变迁》,北京:北京大学出版社,2015年,第35页。

② 马克昌将刑事政策具体区分为刑事立法政策、刑事司法政策、刑事执行政策。(参见马克昌:《论宽严相济刑事政策的定位》,《中国法学》2007年第4期)

③ 陈兴良:《宽严相济刑事政策研究》,《法学杂志》2006年第1期。

④ 有学者提出,应将刑事政策范围仅保留在刑事司法之中。(参见孙万怀:《宽严相济刑事政策应回归为司法政策》,《法学研究》2014年第4期)

1997年《刑法》中关于“破坏环境资源保护罪”的立法,表明我国确立了较为严格的环境刑事政策,但1997年以来至2010年前后,我国同期的环境政策则在一定程度上表现为“经济发展优先、适度保护环境”,两者之间存在一定的紧张关系,污染环境领域存在刑事判决阙如现象也就不足为怪了。^①党的十八大以来,习近平总书记关于“绿水青山就是金山银山”^②及生态文明建设的一系列重要论述表明,我国已经进入了从严保护生态环境的新时期,环境政策制约生态环境犯罪惩治的根本性障碍已经消除。

环境正义与刑事正义的二分是环境司法中司法官思维的主要梗结。作为裁判者的法官,同时也是伦理学意义上的主体,而环境正义作为一种伦理系统,“主要包括环境正义理念、环境正义规范、环境正义德性三个方面。”^③法官虽然熟悉环境正义规范,但在裁判过程中将不可避免地受到自身环境正义理念与环境正义德性的影响,在以文本体系作为判断标准时,不可避免地受到其自身道德理性甚至地方性知识的影响。

实现环境正义与刑事正义的耦合还存在两种不同正义观认识论的差异问题。虽然环境正义已经演化为法律规范体系,但生态环境的公共性使人们所衍生出的正义观具有浓厚的整体主义色彩,在此种正义观念之下人们追求生态环境得到保护的结果,而较少关注为实现环境保护目的而采取的方式与手段的合规性、合法性甚至道德符合性。为追求环境保护的效果而不惜一切代价、一切手段,认为自身所从事的行为皆符合正义,可能会演化为“环境恐怖主义”^④而对法治造成破坏。

环境犯罪中的刑事正义既表现为犯罪行为被否定评价、行为人被刑法惩治,也表现为行为人受到了刑法的公正对待,而没有被滥施刑罚或剥夺自由与财产。个案公正是刑事正义的载体。部分地区的司法机关为回应国家运用刑法手段惩治污染环境犯罪的政策,过度追求环境保护的目的,在个案中对行为人的辩护关注有限,对不同入罪标准的关系掌握有限,对主客观相一致的认知程度有限,粗糙定案的现象还较为严重。

① 参见焦艳鹏:《我国环境污染刑事判决阙如的成因与反思——基于相关资料的统计分析》,《法学》2013年第6期。

② 2013年9月7日,习近平总书记在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲并回答学生们提出的问题,在谈到环境保护问题时他指出:“我们既要绿水青山,也要金山银山。宁要绿水青山,不要金山银山,而且绿水青山就是金山银山。”(中共中央宣传部:《习近平总书记系列重要讲话读本》,北京:学习出版社、人民出版社,2014年,第120页)

③ 刘湘溶、张斌:《环境正义的三重属性》,《天津社会科学》2008年第2期。

④ 环境恐怖主义(environmental terrorism),又称生态恐怖主义(ecological terrorism),是指为了追求环境保护效果,而不惜采取类似于恐怖袭击的方式对政府或社会施加影响的一种极端社会思潮。

改变上述状况的出路在于,要认识到环境刑事政策虽是环境领域的刑事政策,但在本质上作为刑事政策之一种,仍应通过司法判决体现正义。要坚持案件判决书是运送刑事正义的唯一载体的观念,加强对个案的精细化司法,以刑法机制的有效发挥促进环境法治,进而促进环境保护,实现法治文明与生态文明的统一。

六、结 语

生态文明建设是全面建设小康社会的重要目标,需要强有力的法治保障。在生态文明建设中,刑法既负有重要使命,也面临巨大挑战。既有刑法在保护传统的财产法益、人身法益等方面所具有的机制优势在生态文明保障中存在效用边界。需在现有刑法机制基础之上,以有效保障生态文明建设为目标,尽快建立包括生态法益在内的多元法益保障的刑法机制。加快建设生态文明保障的刑法机制,对于提升刑法在生态文明时代的适应性、保障国家生态安全、控制生态环境风险、提升公众安全感具有重要意义。

生态文明的刑法保障,核心在于对生态法益的保障。生态法益作为人对生态环境具有正当合理需求的权利或利益,是环境犯罪所侵害的实质客体。建设生态文明保障的刑法机制,需在刑事立法机制与刑事司法机制两个主要方面着力。在刑事立法机制建设方面,应注重刑法多元机能的协调配置,将自然资源的生态价值法益化,并努力实现生态法益的类型化、具体化、可测量化,使惩治环境犯罪的刑事立法做到体系完整、结构合理、罪状清晰、罪刑相当,不断提升环境刑事立法的科学性;在刑事司法机制建设方面,需加强司法官对生态环境案件的法益衡量能力,以充分辩论、有效辩护等为工具推进庭审实质化,在个案中实现对生态法益的有效识别与度量,进行精细化司法,努力促进个案公正。

生态文明保障的刑法机制的有效运行,有赖于国家整体治理能力的提升与治理体系的现代化。保障生态文明,需充分运用刑法机制,同时也要认识到刑法功能的有限性,刑法机制的运作需要法治系统中其他法律机制的协调配置与功能衔接,在法治系统视野之下,加强刑法机制与宪法机制、行政法机制、环境法机制等的系统连接与功能共建。在生态文明时代,人的法益趋向多元化与复杂化,刑法需作出更多调校与适应。

〔责任编辑:刘 鹏〕